

1500956-71.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... com a natureza permanente do tráfico de drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART.

35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM COM

BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500956-71.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500956-71.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237839/2021 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 4, 19976488 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 78/21/567 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2237839 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ITALO ABADE DA SILVA CERQUEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Italo Abade da Silva Cerqueira e Maurício Yassu, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, os réus, no dia 31 de agosto de 2021, às 07h30min, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foram surpreendidos associados com o fim de cometer, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Ainda, segundo a exordial, os réus, no dia 31 de agosto de 2021, às 07h30min, na Rua João Sotero de Castro, número 4-064, bairro Chácaras Cornélia, e na Rua Baden

Powell, número 1-026, bairro Residencial Elza, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, previamente associados e com identidade de propósitos, mantinham em depósito 501,79 gramas de tetraidrocanabinol, 24,14 gramas de cocaína, 5,9 gramas de MDMA, 7,96 gramas de LSD e 55,42 gramas de N-BUTILPENTILONA, para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 19/23), auto de exibição/apreensão (fls. 24/27), laudo de constatação preliminar (fls. 31/58), laudo definitivo (fls. 167/175), laudos dos celulares/computadores (fls. 374/383, 394/405, 409/413).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a análise da legalidade do ato (fls. 113/117), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Em sede de habeas corpus nº 2216124-11.2021.8.26.0000, da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça foi concedida a ordem para deferir a liberdade provisória ao réu Mauricio Yassu, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 188/190, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos réus.

As D. Defesas ofertaram respostas à acusação (fls. 220/221 e 241/262).

A decisão de fls. 281/284 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 356/358, foi ouvida a testemunha Mariana Bella Silva, tendo as partes insistido na oitiva das testemunhas faltantes.

Na audiência em continuação, conforme fls. 460/462, foi ouvida testemunha Thomaz Caique Santos Salzedas. Na mesma ocasião, as partes desistiram da oitiva da testemunha Mônica Alves e a D. Defesa de Rafael Augusto da Silva Alves. No citado ato processual, os réus foram interrogados.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 476/485 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, condenando-se os acusados por ambos os crimes, nos termos da exordial, exasperando-se a pena-base pela quantidade e qualidade de drogas, valorando-se a reincidência e confissão do réu Ítalo, com a constatação, ainda, da agravante do "estado pandêmico", bem como com o afastamento do "tráfico-privilegiado" e a fixação do regime inicial fechado.

A D. Defesa constituída do réu Maurício Yassu às fls. 490/496 pleiteou, em síntese, pela desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, ou pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, substituindo-se a privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Já a D. Defesa constituída do réu Ítalo Abade da Silva Cerqueira, às fls. 497/504, pugnou, em suma, pela inexistência da associação, por ausência das elementares da estabilidade e permanência ou o lançamento da pena-base em montante próximo ao mínimo, compensando-se a confissão com a reincidência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 19/23), auto de exibição/apreensão (fls. 24/27), laudo de constatação preliminar (fls. 31/58), laudo definitivo (fls. 167/175), laudos dos celulares/computadores (fls. 374/383, 394/405, 409/413).

As autorias, de outra banda, são certas, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais civis Fabio Souza da Silva e Mariane Bella Silva, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em resumo, que o DEIC de Sorocaba iniciou uma investigação acerca da venda de drogas sintéticas. Afirmaram que identificaram o réu Ítalo como um dos fornecedores, sendo que ele era morador de Mairinque, cidade na região de Sorocaba, mas residia em Bauru. Informaram que foram deferidas a interceptação telefônica e a quebra de sigilo telemático. Esclareceram que obtiveram acesso a vídeos e imagens do telefone de Ítalo com fotos de drogas, tais como: haxixe e 'shatter' (droga até então desconhecida dos meios policiais), tendo acesso, ainda, às transferências de valores, via 'pix', que ele recebeu, o que girava em torno de trinta mil reais mensais. Mencionaram que descobriram que o ora sentenciado Maurício fazia os pagamentos 'via pix', para o corréu Ítalo, em montantes que

giravam entre dez mil a doze mil reais. Citaram que o réu Maurício não só fazia a transferência de valores, mas, em certas ocasiões, ele recebia pagamentos, via pix, por parte do réu Ítalo. Asseveraram que, no cumprimento do mandado de busca, uma equipe da polícia foi até a casa do réu Maurício, onde acharam drogas: maconha, haxixe, ecstasy e shatter. Disseram que outra equipe da polícia foi até a casa de Ítalo, onde também foram encontradas drogas semelhantes. Afirmaram que Patrícia e Adnan, testemunhas protegidas nos termos do relatório policial de fls. 157/159, faziam transferência, 'via pix', ao réu Ítalo e citaram que eram apenas usuários. Informaram que a droga shatter custa 120 reais a grama e tem como destinatários pessoas de classe social mais elevada. Esclareceram que o réu Ítalo já foi processado por tráfico em Mairinque.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha Mônica Alves, ouvida apenas na fase policial (fls. 10), assim se pronunciou: Que conheceu Ítalo acerca de 4 anos em São Paulo e passou a se relacionar com ele desde então. Cerca de um mês depois ele foi preso pela prática de tráfico de drogas e quando saiu da prisão passaram a morar juntos ainda na capital. Depois de oito meses vieram morar Bauru onde a mãe da testemunha já residia. A depoente trabalha como consultora de crédito imobiliário e Ítalo atualmente não tem trabalho, mas há seis meses atrás ele fazia "bicos" em uma lanchonete. Ao todo mora com Ítalo em Bauru há cerca de dois anos, sendo que no último ano ele voltou a traficar drogas. Tinha conhecimento que Ítalo vendia várias espécies de maconha em diversas e também drogas sintéticas. Essa é a 3ª vez que Ítalo é preso pela prática de tráfico de drogas e tinha brigas constantes com ele em razão disto, já que sempre lhe pedia para parar. Presenciou os Policiais encontrarem drogas em sua casa na manhã de hoje.

A testemunha de defesa Thomaz Caique Salzedas, ouvido sob o manto do contraditório (mídia SAJ), nada elucidou acerca dos fatos.

O réu Maurício Yassu sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) permaneceu em silêncio.

Já o réu Ítalo Abade da Silva Cerqueira confessou o tráfico. Disse, em resumo, que estava dormindo, quando policiais invadiram sua residência, na posse de um mandado de busca e encontraram entorpecentes, que seriam para seu consumo. Afirmou que foram encontrados maconha, shatter (droga derivada da maconha), haxixe, cocaína e LSD. Informou que vendia parte da droga para sustentar seu vício. Esclareceu que, geralmente, vendia 'o ecstasy em festas rave'. Mencionou que é amigo do corréu Maurício.

Pela prova colhida, de rigor a condenação por ambas as infrações penais.

É dos autos que extensa e pretérita investigação da Polícia Civil de Sorocaba foi inaugurada visando, justamente, elucidar o tráfico de drogas sintéticas.

Com a busca e apreensão deferida, encontraram, na casa do réu Maurício, maconha, haxixe, ecstasy e shatter, e, na casa de Ítalo, entorpecentes semelhantes.

Ou seja, a apreensão dos entorpecentes é de per si é suficiente para incriminar os réus, já que as substâncias eram mantidas em depósito, e, além disso, o delito em questão, no tocante à citada elementar, é de perigo abstrato.

Ainda durante as investigações, em quebras de sigilos telemáticos obtiveram acesso a vídeos e imagens do telefone de Ítalo com fotos de drogas como: haxixe e shatter (droga até então desconhecida dos meios policiais), tendo acesso, ainda, às transferências de valores via "pix" que ele recebeu, o que girava em torno de trinta mil reais mensais.

Também restou elucidado que o sentenciado Maurício fazia os pagamentos via "pix", para o réu Ítalo, montantes que giravam entre dez mil a doze mil reais, sendo que, Maurício não só fazia a transferência de valores, mas em certas ocasiões ele recebia pagamentos via "pix", por parte do réu Ítalo.

Tais conclusões podem ser extraídas da análise do constante às fls. 370/373, 384/393 e 406/408, além da prova pericial acostada.

Tais razões denotam que a associação também estava caracterizada.

Com efeito, os réus são amigos. Depois, as drogas semelhantes foram apreendidas na residência de ambos. Além disso, faziam transferências cruzadas de "pix" de montante vultuosos.

As aludidas circunstâncias denotam a permanência, vista como a vontade em permanecer associados, até porque parte da droga (shatter) era então desconhecida nos meios policiais.

Insta salientar que Ítalo comercializava os entorpecentes, fato confirmado por Mônica (companheira), além de Adnan e Patrícia, usuários (fls. 368).

O réu Maurício também comercializava os entorpecentes, visto que recebia, por vezes, transferências via "pix" do sentenciado Ítalo.

Já a estabilidade, qualificada pelo tempo, pode ser delineada pela extensa investigação, compatível com a natureza permanente do tráfico de drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem apontaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência do crime de associação para o tráfico, consistentes em prévia investigação policial realizada no endereço do casal, sendo evidenciado que o comércio de entorpecentes era realizado por todos os moradores do local, bem como em depoimentos de testemunhas que confirmaram a aquisição de drogas tanto da Agravante, quanto do Corréu, há no mínimo 4 (quatro) meses.

2. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,

"mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito" (HC 600.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 723467 / SC, ministra Laurita Vaz, julgado em 22/03/2022)

Deste modo, as circunstâncias evidenciam que os crimes foram cometidos, o que, em consequência, não permite a desclassificação da conduta de tráfico, para a infração sui generis de consumo pessoal (tese do corréu Maurício).

Sob outro aspecto, deve o sentenciado Ítalo deve permanecer custodiado.

Como dito, possui em seu desfavor reincidência específica.

Ademais, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, denotam que a ordem pública deve ser preservada.

No sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RELEVANTE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. GRAVE MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na relevante quantidade de droga arremessada ao presídio (545 gramas de maconha e 60 comprimidos coloridos de ecstasy), além de 87 gramas de maconha e 10 comprimidos coloridos de ecstasy apreendidos pessoalmente, o que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 154193 / RS, RHC 154193 / RS, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 26/10/2021)

Em acréscimo, a manutenção da custódia serve para evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE. DIFICULDADE DE CITAÇÃO DOS CORRÉUS QUE RESPONDEM EM LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDAS AO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - 2kg (dois quilos) de maconha -, e destacada a reincidência específica da agente. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

4. No caso em exame, o pequeno atraso para o início da instrução se deve à complexidade do feito, a que respondem 3 réus com representantes distintos, dois

deles beneficiados com a liberdade provisória, os quais não foram encontrados na primeira tentativa de citação, agora restando um dos corréus, que será citado por edital, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para início da instrução criminal, por nítida ausência de desídia ou paralização do juízo processante, que, contrariamente, tem envidado todos os esforços para dar regular andamento ao feito. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente em se tratando de imputação pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o mesmo fim e corrupção de menores.

5. Recurso ordinário desprovido, recomendando, no entanto, ao Juízo de origem que imprima celeridade para o início da instrução criminal da Ação Penal n. 0050683-10.2020.8.06.0095.

(STJ, 6ª Turma, RHC 148889 / CE, relator ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 14/10/2021)

O réu Maurício teve a seu favor concedida a liberdade provisória, com a imposição de cautelares, e não há, no momento, pautado na cláusula rebus sic stantibus modificação fática relevante a ponto de alterar tal determinação, até porque de ordem superior ao juízo monocrático.

Passo à fixação da pena.

Tráfico de drogas

Réu Ítalo Abade da Silva Cerqueira

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a quantidade, parte da natureza (cocaína) e diversidade dos entorpecentes, denotam que a pena deve ser exasperada em 2/5, perfazendo 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Aliás, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que tais circunstâncias - quantidade e natureza - são preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela r. jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosas.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e

justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado é reincidente específico, entretanto, confessou o delito de tráfico.

Deste modo, as circunstâncias devem ser compensadas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido.

(STJ, 3ª Seção, REsp 1341370 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA

ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.

FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E

QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO

TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema.

(...)

(STJ, 3ª Seção, HABEAS CORPUS Nº 365.963 - SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/10/2017)

Ainda na fase intermediária, a agravante do "estado pandêmico" deve ser afastada.

Primeiro, o crime foi elucidado após a revogação do Decreto Legislativo nº 6/2020.

Além disso, não há informações que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada

a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se

demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da

participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso

VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva

de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é reincidente específico.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e

na derradeira, por que o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressaltadas as hipóteses legais.

Já na última fase, é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Depois, a quantidade, variedade e natureza de drogas, denotam que o tráfico já era realizado no local há algum tempo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 500 G DE CRACK E 4,33 G DE COCAÍNA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONVICÇÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO AO CRIME CALCADA NÃO APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS, MAS TAMBÉM NA APREENSÃO DE PETRECHOS LIGADOS AO FABRICO, EMBALO E COMÉRCIO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE QUE A DROGA NÃO PERTENCIA AO RÉU, MAS SIM AO CORRÉU. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1208408 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018)

Por isso, a pena atingida na fase inicial é a definitiva.

Réu Maurício Yassu

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

A ré não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A coletividade (saúde pública) foi maculada nos estritos termos do tipo legal.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a quantidade, parte da natureza (cocaína) e diversidade dos entorpecentes, denotam que a pena deve ser exasperada em 2/5, perfazendo 7 (sete) anos e 700

(setecentos) dias-multa, forte na preponderância insculpida no art. 42 da Lei Antidrogas.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias legais.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena-base é a definitiva.

Com efeito, comprovada também a associação para o tráfico, incabível a benesse prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES OCORRIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE QUANDO RECONHECIDA A AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível a aplicação da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 quando ocorrer a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Precedentes. 2. Mostra-se manifestamente infundada a tese sustentada pela Defesa que o exame do recurso especial esbarraria na Súmula n.º 07/STJ. Ora, os Acusados foram condenados por associação para o tráfico. Assim, comprovado no acórdão recorrido a prática do crime, o qual sequer foi impugnado pela Defesa, é possível o afastamento da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sem necessidade de reexaminar as provas dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1292271 MG 2011/0274834-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2012)

Associação para o tráfico

Réu Ítalo Abade da Silva Cerqueira

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a reprimenda é de 3 (três) anos e reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o sentenciado é reincidente.

Portanto, a pena deve ser agravada em 1/6, perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentas e dezesseis) diárias.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição.

Réu Maurício Yassu

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a reprimenda é de 3 (três) anos e reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias legais.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição.

Em razão da ocorrência do concurso material de delitos, face a mácula a bens jurídicos diversos, as penas devem ser somadas.

Deste modo, totalizam: 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa, para o réu Italo Abade da Silva Cerqueira; e 10 (dez) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, para o réu Maurício Yassu.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, nos moldes das informações de vida pregressa de fls. 59/60.

Fixo o regime inicial fechado para ambos os acusados.

O réu Italo é reincidente específico, além disso, a pena é superior a 8 (oito) anos de reclusão, nos moldes do art. 33, §2º "a" do Código Penal.

Já o réu Maurício, ainda que não reincidente, foi à pena que ultrapassa, também, o lapso de 8 (oito) anos, devendo cumprir a reprimenda em Penitenciária.

Ademais, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Além disso, a droga estava em depósito na residência de ambos, sendo utilizada, ainda, em comercialização durante festas (Rave), o que denota que o regime mais gravoso é o único necessário e suficiente para a reprovação do crime.

Os montantes de pena, impedem a substituição da privativa, por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e, deste modo: CONDENO o réu Italo Abade da Silva Cequeira, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 "caput" e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

CONDENO o réu Maurício Yassu, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 "caput" e 35 ambos da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado Italo o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados, expedindo-se o pertinente ofício de recomendação.

Tendo em vista que os objetos apreendidos foram enviados à DEIC – Deinter 7 de Sorocaba/SP, inclusive através de lá periciados, o que denota que as investigações permanecem, deixo de determinar a perda (fls. 165).

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição (fls. 24/27).

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA